

刑法
No219

H27-6 (配点: 2)

月	日
月	日

次の1から5までの各事例における甲のVに対する罪責について、判例の立場に従って検討した場合、甲に殺人罪が成立しないものはどれか。

1. 甲は、Vには自殺がどのようなものかを理解する能力がなく、しかもVが甲の命ずることには何でも服従するのを利用してVを死亡させようと考え、Vに対して、首を吊る方法を教えた上、これを実行するよう命じた。Vは、甲から命じられたとおりに、教えられた方法で自ら首を吊って窒息死した。
2. 甲は、真冬の深夜、河川堤防でVに激しい暴行を加えたところ、Vは走って逃げ出した。甲は、逃げるVを堤防際まで追い詰めれば、逃げ場を失ったVが堤防から下の川に飛び込んで溺死するかもしれないがそれでも構わないと考え、Vを堤防際まで追い詰めた。逃げ場を失ったVは、甲からの暴行を免れるため、堤防から約3メートル下の川に飛び込んで溺死した。
3. 甲は、Vから、包丁で腹部を突き刺して殺してほしいと依頼され、これを真意から出た依頼であると信じて包丁でVの腹部を突き刺したが、その依頼はVの冗談であって、Vの真意から出たものではなかった。Vは、甲から腹部を包丁で刺されたことにより失血死した。
4. 甲は、妻と話し合って一家心中することとし、妻と5歳になる息子Vからそれぞれ一家心中することの承諾を得た上、妻とVを殺すため、同人らの腹部を包丁で刺した。妻とVは、甲から腹部を包丁で刺されたことにより失血死した。
5. 甲は、Vから心中を持ち掛けられたことを利用して、Vを死亡させようと考え、自らは死ぬ気がないのに、Vとの心中を了承した。Vは、甲の真意を知っていれば死ぬことはなかったが、甲と一緒に死んでくれるものと誤信したまま、甲の目の前で、甲が用意した致死量の毒を飲んで中毒死した。

No219	殺人罪の成否	正答率
H27-6	正 解	91%

1 成立する

最決昭27.2.21。判例は、本記述と同様の事案において、「刑法202条を以て間擬しないで同法199条を適用したのは正当であ」としている。202条の生命処分の意味は、死の意味を理解し自殺について自由な意思決定の能力を有する者でなければならないからである。Vには自殺がどのようなものを理解する能力がないので、甲に自殺関与罪は成立せず、甲がVに対して、首を吊る方法を教えた上、これを実行するように命じて、これを実行させた行為は、殺人罪の実行行為に当たる。

2 成立する

最決昭59.3.27。判例は、本記述と同様の事案において、「被告人の所為は殺人罪にあたる」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、被害者に対する暴行、脅迫により、被害者の自由な意思の働く余地のないほど被害者を強制した場合には、被害者自身の行為を利用した間接正犯を肯定できるということを挙げている。本記述では、Vは、甲からの激しい暴行を免れるため、真冬の深夜に川に飛び込んでいる。Vは甲の暴行により、自らの意思に基づくことなく川に飛び込むことを強制されているといえ、V自身の行為を利用した殺人罪の間接正犯が肯定できる。

3 成立しない

本記述では、行為者甲の認識・予見した事実が該当すべき構成要件は同意殺人罪であり、実際に発生した事実が該当する構成要件は殺人罪であるため、抽象的事実の錯誤が生じている。この場合、刑法は「重い罪によって処断することはできない」（38条2項）と規定しており、殺人罪は成立しない。もっとも、行為者が同意の存在を誤信して、それを有しない者を殺害した場合、同意殺人罪と殺人罪の構成要件が実質的に重なり合う限度で、軽い同意殺人罪が成立する（38条2項参照）とされている。本記述では、甲は、Vの冗談を真意から出た依頼であると信じて行為に及んでいる。したがって、甲には同意殺人罪が成立し、殺人罪は成立しない。

4 成立する

大判昭9.8.27。判例は、本記述と同様の事案において、普通殺人罪を適用するとしている。同意殺人罪が成立するためには、被殺者の有効な被殺意思が必要であり、そのためには、死の意味を理解し得る精神能力が必要であるところ、それを欠く者には有効な同意を認めることはできないからである。本記述では、5歳になる息子Vは死の意味を理解し得る精神能力を欠く。

5 成立する

最判昭33.11.21。判例は、本記述と同様の事案において、「被告人に追死の意思がないに拘らず被害者を欺罔し被告人の追死を誤信させて自殺させた被告人の所為は通常の殺人罪に該当する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、欺罔により自殺意思を生じさせた場合、欺かれなければその意思を形成しなかったと認められるとき、それは「真意に添わない重大な瑕疵ある意思」であって無効となり、欺いた者には殺人罪が成立するとしている。本記述では、甲は自らは死ぬ気はなく、Vは甲の真意を知っていれば死ぬことはなかった。